

1501214-19.2022.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDO JOSE ALGUZ DA SILVEIRA

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/11/2022

... do Estado de São Paulo:

"APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - PROVA - SUFICIÊNCIA - Materialidade e autoria comprovadas - Réu preso em flagrante - Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes - Conduta do apelante que se amolda ao verbo-tipo trazer consigo do artigo 33 da Lei de Drogas - Tipo misto alternativo em que basta que a conduta se subsuma a qualquer ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí

Foro de Tatuí

2ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Tatuí-SP - cep 18278-440

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501214-19.2022.8.26.0571 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501214-19.2022.8.26.0571

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2248032/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 27335864 -

DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2248032 - DEL.POL.CAPELA DO ALTO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FLAIANE TAIANE VIEIRA DIAS

Réu Preso

Tramitação prioritária

1º Juiz(a) de Direito Auxiliar: Dr(a). FERNANDO JOSE ALGUZ DA SILVEIRA

Vistos.

FLAIANE TAIANE VIEIRA DIAS, já qualificada nos autos, foi denunciada e está sendo processada como incurso na figura típica descrita no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06 com incidência da agravante disposta no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, pois, consoante relata a denúncia, no dia 11 de setembro de 2022, por volta das 02h00, na Rua Luiz Galavotti, nº 10, no Bairro Casa Grande, na Cidade de Capela do Alto e Comarca de Tatuí, nas imediações de escola e de Igreja, bem como em ocasião de calamidade pública, trazia consigo drogas consistentes em 18 (dezoito) porções de Cannabis

Sativa L, popularmente conhecida como "maconha", com peso bruto aproximado de 51,69 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A ré foi notificada (fl. 73) e ofertou a sua defesa prévia (fl. 78).

A denúncia foi recebida no dia 22 de novembro de 2022 (fls. 88/89) e a acusada foi citada (fl. 99).

Durante audiência foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas e, ao final, a ré foi interrogada. A instrução foi encerrada e as partes ofertaram suas alegações finais orais (fls. 100/104).

Os autos vieram para a conclusão.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Cuida-se de ação penal pública incondicionada que tramita em desfavor de FLAIANE TAIANE VIEIRA DIAS, a qual, segundo consta da peça inicial acusatória, transgrediu o preceito primário da norma penal incriminadora inserida no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, com incidência da agravante disposta no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal.

Cotejadas as provas colhidas nesta ação penal, de rigor o parcial acolhimento da pretensão punitiva com a condenação da ré pela prática do delito a ela atribuído, afastando, todavia, a agravante disposta no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal e a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06.

Deveras, sabe-se que é necessário, para toda e qualquer condenação, que exista juízo exauriente acerca da autoria e materialidade delitiva.

A materialidade do delito está comprovada através do boletim de ocorrência de fls. 13/14, auto de exibição e apreensão de fl. 16, auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fl. 17, comprovante de depósito judicial de fls. 45/46, informação sobre o local dos fatos de fls. 47/48, laudo de exame químico toxicológico definitivo de fls. 49/52 e pela prova oral colhida.

De igual modo, a autoria é inconteste.

Feitas as considerações iniciais, passa-se à análise da prova colhida em audiência. Durante a instrução, a testemunha FERNANDO CARRON DE FREITAS, policial militar, informou que na data dos fatos, por volta das 02h00, sua equipe efetuava patrulhamento e encontrou com a ré que, na ocasião, estava com uma pochete em sua cintura. Inicialmente avistaram apenas um volume, razão pela qual deliberaram pela abordagem. Constataram que o volume consistia em uma bolsa preta contendo em seu interior os entorpecentes, bem como certa quantia em dinheiro. O local da abordagem é conhecido como ponto de venda de drogas. A acusada estava parada na via pública. Questionada, Flaiane Taiane confessou que realizava a comercialização das drogas no bar que lá havia. Disse que não conhecia a ré. Havia pessoas próximas, mas não estavam com a acusada.

O policial militar LUCAS FRANÇA OLIVEIRA ratificou na íntegra o depoimento prestado por Fernando Carron de Freitas. Salientou que em patrulhamento pelo Bairro Cercadinho, sua equipe avistou a acusada com um grande volume em sua cintura. Abordada, a própria ré levantou sua camiseta, sendo possível constatar que o volume observado era uma bolsa na qual havia entorpecentes e dinheiro. Disse ter trabalhado por pouco tempo no Município de Capela do Alto, mas a população sempre indicou o local dos fatos como ponto de comércio de drogas. Indagada, a ré confirmou a venda de drogas no local. Por fim, disse que antes da abordagem já ouviu falar sobre a acusada.

Por sua vez, perante a Autoridade Policial, a ré FLAIANE TAIANE VIEIRA DIAS manifestou o desejo de permanecer em silêncio (termo de interrogatório de fl. 08). Durante seu interrogatório judicial, informou que possui condenação anterior pela prática do crime de receptação. Trabalhava na roça e residia com sua mãe na Cidade de Capela do Alto. Disse que não foi abordada com nenhuma pochete. As drogas com ela apreendidas eram destinadas ao seu consumo e estavam em seu bolso. Havia acabado de adquirir as drogas pelo valor de cento e oitenta reais. O dinheiro apreendido era proveniente de seu trabalho. Destacou que, por conta de pedido feito por sua mãe, adquiriu uma quantia maior de drogas para não precisar retornar ao local da compra com frequência. Faz uso de maconha, crack e cocaína. Consome

maconha com frequência. Informou que os policiais responsáveis por sua prisão já a haviam abordado em outras ocasiões, sob a suspeita de que estaria traficando. Não sabe o motivo de tal suspeita. Questionada pela Defesa sobre o porquê estava na rua durante a madrugada, disse que havia retornado de um baile funk, preparou-se para trabalhar e passou no local para comprar as porções de maconha. Sai de casa para trabalhar às 03h00. Utiliza maconha desde os seus nove anos de idade.

Ao final da instrução, em que pese a negativa da acusada quanto à prática do crime a ela imputado, a prova coligida é robusta, clara e sólida a embasar o decreto condenatório.

Segundo ficou delineado pelo conjunto probatório, durante patrulhamento de rotina, durante a madrugada, ao passarem por local conhecido como ponto de comércio de drogas, policiais militares avistaram a acusada parada na via pública ostentando um volume em sua cintura.

A fim de averiguar a situação, efetuaram a abordagem da ré. Flaiane Taiane levantou sua blusa e foi possível observar que o volume consistia em uma bolsa preta contendo em seu interior dezoito porções de maconha e quarenta e seis reais em dinheiro.

Indagada, a ré confessou a prática da venda de drogas no local, razão pela qual a equipe policial efetuou sua prisão e condução à Delegacia de Polícia para registro da ocorrência.

Tais questões estão embasadas pela prova testemunhal e demais elementos carreados aos autos.

As palavras dos agentes de segurança foram uníssonas e seguras acerca dos fatos retratados na denúncia, sendo certo que, nas oportunidades em que ouvidos, apresentaram versões concretas acerca da materialidade e autoria do delito perpetrado pela ré.

Saliente-se, tanto doutrina quanto jurisprudência são uníssonas em afirmar que os depoimentos prestados por agentes de segurança devem ser críveis até prova em contrário. Os depoimentos prestados pelos policiais militares, como servidores públicos que são, gozam de credibilidade, sendo seus testemunhos plenamente válidos, até porque inexistem impedimentos de ordem moral para afastá-los.

A esse respeito, observo que "Os servidores públicos, inclusive policiais, empobrecidos que são após formal compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunho ou em documentos oficiais oferecem a seus superiores e à Justiça, sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes." (RT 411/26).

Não obstante, frise-se que seus depoimentos foram submetidos ao crivo do contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito.

A versão ofertada em juízo pela ré acerca dos fatos não merece credibilidade, porquanto isolada e dissociada dos autos.

Com efeito, Flaiane Taiane informou ser apenas usuária de drogas e, na data dos fatos, acabara de adquirir as porções com ela apreendidas para o seu uso. Ainda, para justificar a razão de ter sido flagrada às 02h00 em local conhecido como ponto de venda de drogas, indicou que retornou de um baile funk, arrumou-se para trabalhar e passou no local para adquirir as porções de maconha.

A despeito do quanto pela ré foi informado, seu relato não se presta a influir no convencimento deste juízo, merecendo prestígio todos os elementos bem delineados pela prova coligida, notadamente os seguros depoimentos prestados pelos agentes de segurança responsáveis pela diligência que culminou na constatação do ilícito.

Ora, não é crível que a ré, durante a madrugada, seja abordada enquanto estava parada com dezoito porções de maconha preparadas para a sua disseminação e quantia em dinheiro, em local conhecido como destinado à prática espúria da venda de drogas, ali esteja tão somente para a aquisição de drogas.

Não pode prevalecer a autodefesa da acusada no sentido de que as drogas que com ela foram apreendidas se destinavam ao seu consumo e, por consequência, não comporta acolhimento a desclassificação do delito a ela atribuído para aquele previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, porquanto nenhum elemento de informação foi

apresentado a fim de fomentar a alegada mera condição de usuária.

Sequer as provas amealhadas sugerem referida postura da ré. Não fosse isso, é indene de dúvidas que muitos usuários entram no tráfico para custear a compra de drogas para uso próprio (a denominada figura do "traficante-usuário").

Até mesmo a quantidade de entorpecentes apreendidos, incompatível com o consumo imediato de apenas uma pessoa, sem qualquer instrumento comumente utilizado para tanto, refuta a condição de mero usuário de substâncias entorpecentes, inviabilizando a desclassificação pretendida.

E mais, em que pese tenha sugerido que é dependente química, não apresentou qualquer documento médico ou, ainda, arrolou testemunhas que pudessem confirmar tal alegação, restando, pois, desprovida de credibilidade.

Acrescento que o fato de ser eventualmente usuária, afirmado apenas e tão somente na pouco crível versão da acusada, não afasta a sua relação com o comércio ilícito de drogas, pelo contrário, facilita tal espécie de atuação, diante do irrestrito acesso a outros usuários, seus consumidores e traficantes.

Neste sentido, inclusive: "A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade." (RJTJSP 101/498).

Em suma, as circunstâncias dantes apontadas para a caracterização da narcotraficância afastam sobremaneira a desclassificação pretendida.

Diante de todo o contexto, inegável que a conduta da acusada se amolda perfeitamente ao verbo-tipo "trazer consigo", previsto no preceito primário da norma penal incriminadora prevista no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Nesse sentido a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - PROVA - SUFICIÊNCIA - Materialidade e autoria comprovadas - Réu preso em flagrante - Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes - Conduta do apelante que se amolda ao verbo-tipo trazer consigo do artigo 33 da Lei de Drogas - Tipo misto alternativo em que basta que a conduta se subsuma a qualquer dos verbos-tipo para a caracterização da infração - Desnecessidade de dolo específico para a caracterização do tráfico - Negativa do réu isolada diante das demais provas coligidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa - PENA - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - TRÁFICO PRIVILEGIADO - CIRCUNSTÂNCIAS ADVERSAS À CONCESSÃO DA BENESSE - "REFORMATIO IN PEJUS" - IMPOSSIBILIDADE - Aplicado pelo MM. Juízo redução de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, no patamar de um terço - Maus antecedentes do réu comprovados por Certidão - Impossibilidade de aplicação do redutor por expressa vedação legal - Recurso apenas da Defesa, o que impossibilita a "reformatio in pejus" - SENTENÇA - ERRO MATERIAL - CORREÇÃO - Determinação para que, no dispositivo da sentença, conste a condenação do réu por infração do artigo 33, "caput", da Lei nº. 11.343, de 23 de agosto de 2006, à pena de três anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de trezentos e trinta e três dias-multa, no valor mínimo legal - Sentença condenatória mantida, com retificação 'ex officio' - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO." (TJ-SP - Apelação Criminal nº 9090093-75.2008.8.26.0000, Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal;

Relator(a): Desembargador(a) Amado de Faria; Origem: Comarca São José dos Campos; Julgamento e Publicação: 06.10.2011 e 13.10.2011) - sem destaques no original.

"Rejeição da Denúncia - Fundamento insubsistente - A conduta descrita na denúncia está tipificada no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 - Quantidade de droga que autoriza a imputação - Princípio da insignificância que, por outro lado, não tem aplicação em nosso ordenamento jurídico, principalmente em se tratando do grave delito de tráfico de entorpecentes - Tratando-se de crime de ação múltipla, não é necessária a prática de atos de mercancia, bastando, para o seu reconhecimento, que se realize um dos verbos do tipo penal. Recurso provido a fim de receber aquela peça." (TJ-SP - Recurso em Sentido Estrito nº 0008243-89.2014.8.26.0050; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Relator(a): Desembargador(a) Marcos Corrêa; Origem: Comarca de São Paulo; Julgamento e Publicação: 30.04.2015 e 04.05.2015) - sem destaques no original.

"Tráfico de drogas. Autoria e materialidade do crime fartamente comprovadas. Exame pericial constatando que a substância apreendida é cocaína. Palavra das testemunhas

policiais e confissão do apelante de que guardava entorpecentes para terceiro. Configuração do ilícito do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 posto que, independente da mercancia efetiva, esta é somente uma das possibilidades em meio aos múltiplos verbos nucleares do tipo, destinados a repreender todas as movimentações do narcotráfico, inclusive as de "ter em depósito" e "trazer consigo" drogas. Absolvição impossível. Penas bem dosadas, em observância ao art. 42 da Lei nº 11.343/06. Apelo não provido." (TJ-SP - Apelação Criminal nº 0001799-24.2013.8.26.0099; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Relator(a): Desembargador(a) Diniz Fernando; Origem: Comarca de Bragança Paulista; Julgamento e Publicação: 10.08.2015 e 15.08.2015) - sem destaques no original.

Convém lembrar mais uma vez não ser preciso para a caracterização da narcotraficância que o agente seja surpreendido no exato momento em que fornece materialmente a droga a terceira pessoa, bastando circunstâncias seguras de que para tanto se destina o tóxico com ele encontrado, como é o caso dos autos. De mais a mais, a Defesa técnica não produziu nenhuma prova que pudesse favorecer a acusada, limitando-se a postular a sua absolvição e a desclassificação para delito de menor gravidade, teses estas devidamente rechaçadas, conforme tudo aqui exposto. Não obstante, em que pese a informação constante às fls. 47/48, indicando que o fato se deu em imediação de uma escola e de uma Igreja, entendendo não ser possível o reconhecimento da causa de aumento disposta no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas.

A majorante disposta no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas justifica-se pelo fato de que "quanto maior for a aglomeração de pessoas, mais fácil, ágil e disseminado torna-se a mercancia da droga" (NUCCI, Guilherme de Souza Nucci; Leis Penais e Processuais Penais comentadas. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 282).

Ainda, "a justificativa para a existência desta majorante diz respeito à enorme facilidade de disseminação do consumo de drogas nesses locais em virtude da maior concentração de pessoas, o que acaba por representar maior risco à saúde pública." (LIMA, Renato Brasileiro; Legislação Criminal Especial Comentada. 4. ed. Salvador: JusPODIVM, 2016, p. 793).

Como se sabe, a majorante em destaque é de natureza objetiva, não sendo necessária a análise da intenção do agente em comercializar drogas diretamente aos frequentadores dos estabelecimentos indicados pelo legislador.

No entanto, em consonância com a jurisprudência atual do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é possível o afastamento da causa de aumento, em caso excepcional, quando inexistir comprovação de que houve o aproveitamento da aglomeração de pessoas ou exposição de frequentadores do local para disseminação das drogas.

Para tanto, confira-se:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INCISO III, DA LEI N.º 11.343/2006. LOCAL DE TRABALHO COLETIVO. CONDUTA PRATICADA EM NOITE DE FERIADO NACIONAL. INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO CONCRETA DE APROVEITAMENTO DE AGLOMERAÇÃO DE TRABALHADORES OU EXPOSIÇÃO DOS FREQUENTADORES DO LOCAL DE TRABALHO COLETIVO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1. Espécie em que o Paciente - reincidente específico - foi condenado ao cumprimento de 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e ao pagamento de 641 (seiscentos e quarenta e um) dias-multa, no regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, c.c. o art. 40, inciso III, ambos da Lei n.º 11.343/2006. 2. As instâncias ordinárias fizeram por incidir a referida causa de aumento, considerando que o delito ocorreu próximo à Rodoviária do Plano Piloto, em Brasília, firmadas na expressão "locais de trabalho coletivo" redigida no dispositivo legal. Hipótese contemplada no art. 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006. 3. No caso, o Paciente foi flagrado no dia 07/09/2017, feriado nacional, às 21h30, sem nenhuma indicação concreta de que houve aproveitamento da aglomeração de trabalhadores para a disseminação de droga ou a exposição dos frequentadores do local de trabalho coletivo pela conduta do Sentenciado. 4. Concessão da ordem de habeas corpus para afastar a aplicação da causa especial de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006." (STJ, HC 454.317/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 26/10/2018) - destaquei.

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DELITO PERPETRADO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. ORDEM CONCEDIDA. 1. A razão de ser da causa especial de aumento de pena prevista no inciso III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 é a de punir, com maior rigor, aquele que, nas imediações ou nas dependências dos locais a que se refere o dispositivo, dada a maior aglomeração de pessoas, tem como mais ágil e facilitada a prática do tráfico de drogas (aqui incluído quaisquer dos núcleos previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/2006), justamente porque, em localidades como tais, é mais fácil ao traficante passar despercebido à fiscalização policial, além de ser maior o grau de vulnerabilidade das pessoas reunidas em determinados lugares. 2. Como, na espécie, não ficou evidenciado nenhum benefício advindo ao paciente com a prática do delito nas proximidades ou nas imediações de estabelecimento de ensino - o ilícito foi perpetrado, tão somente, em um domingo, de madrugada - e se também não houve uma maximização do risco exposto àqueles que frequentam a escola (alunos, pais, professores, funcionários em geral), deve, excepcionalmente, em razão das peculiaridades do caso concreto, ser afastada a incidência da referida majorante. 3. Ordem concedida, para afastar a aplicação da causa especial de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas e, por conseguinte, reduzir a reprimenda do paciente para 3 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 166 dias-multa." (STJ, HC 451.260/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 21/08/2018) - destaquei.

"RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CAUSA DE AUMENTO DA PENA. ART. 40, INCISO III, DA LEI Nº 11.343/2006. INFRAÇÃO COMETIDA NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO EM UMA MADRUGADA DE DOMINGO. AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO DE UMA AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS À ATIVIDADE CRIMINOSA. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. 1. A causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006 tem natureza objetiva, não sendo necessária a efetiva comprovação de mercancia na respectiva entidade de ensino, ou mesmo de que o comércio visava a atingir os estudantes, sendo suficiente que a prática ilícita tenha ocorrido em locais próximos, ou seja, nas imediações do estabelecimento. 2. A razão de ser da norma é punir de forma mais severa quem, por traficar nas dependências ou na proximidade de estabelecimento de ensino, tem maior proveito na difusão e no comércio de drogas em região de grande circulação de pessoas, expondo os frequentadores do local a um risco inerente à atividade criminosa da narcotraficância. 3. Na espécie, diante da prática do delito em dia e horário (domingo de madrugada) em que o estabelecimento de ensino não estava em funcionamento, de modo a facilitar a prática criminosa e a disseminação de drogas em área de maior aglomeração de pessoas, não há falar em incidência da majorante, pois ausente a ratio legis da norma em tela. 4. Recurso especial improvido." (STJ, Resp 1719792/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 26/03/2018) - destaquei.

De igual modo, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a saber:

"APELAÇÃO. Tráfico de entorpecentes. Sentença condenatória. Recurso do Ministério Público. Pleitos objetivando: a) reconhecimento da incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06; b) afastamento da figura do tráfico privilegiado; c) fixação do regime inicial fechado. 1. Condenação adequada. 1.1. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Depoimentos dos policiais militares uniformes e convergentes. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Modelo probatório que não se filiou ao sistema das provas legais, segundo o qual os meios de prova registrariam valores aprioristicamente determinados pelo legislador. Livre convencimento motivado. Versão do acusado que restou isolada no contexto probatório. 1.2. Quantidade e natureza das drogas que, aliadas à presença de porções fracionadas e apreensão de numerário, conduzem à conclusão de que os entorpecentes se destinavam à comercialização. Impossibilidade de desclassificação para o delito previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/2006. 2. Pleito objetivando o reconhecimento da causa de aumento prevista pelo art. 40,

inciso III, da Lei de Drogas. Impossibilidade. A despeito do caráter objetivo da majorante, excepcionalmente admite-se o seu afastamento quando inexistir comprovação de que houve aproveitamento da aglomeração de pessoas ou exposição dos frequentadores do local para a disseminação das drogas. Precedentes do STJ.

Ausência de elementos que comprovem ter o acusado se aproveitado da maior movimentação ocasionada pelos frequentadores da escola e da igreja para a prática delitiva. 3. Dosimetria que não comporta reparos. 3.1. Primariedade e ausência de elementos a apontar a dedicação do réu à prática criminosa ou de seu envolvimento com organização criminosa. Manutenção da figura do tráfico privilegiado com redução no patamar máximo. 3.2. Manutenção do regime inicial aberto. 3.3. Cabimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Afastamento do caráter hediondo uma vez reconhecido o tráfico em sua forma privilegiada.

Substituição por prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana.

4. Recurso conhecido e desprovido.” (TJSP; Apelação Criminal 1502321-

48.2018.8.26.0536; Relator (a): Marcos Alexandre Coelho Zilli; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarujá - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/02/2022; Data de Registro: 23/02/2022) - destaquei.

E, no caso dos autos, considerando que a ré foi detida em flagrante delito por volta das 02h00 do dia 11.09.2022 (domingo), embora nas proximidades de uma escola e uma Igreja, evidente que pelo horário não havia a presença de frequentadores daqueles estabelecimentos no local.

Por isso, não há elemento algum que pudesse indicar ter a acusada se aproveitado do movimento ocasionado pelos frequentadores dos locais indicados para a disseminação de entorpecentes, razão pela qual de rigor o decote da causa de aumento disposta no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06.

Portanto, a condenação da ré se impõe em relação à prática do delito disposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

DOSIMETRIA DA PENA.

Na primeira fase do critério trifásico, atento ao artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/06, observo que a ré ostenta condenação anterior que por caracterizar reincidência, nos termos da Súmula nº 241 do STJ, será ponderada na etapa seguinte.

As demais circunstâncias judiciais não lhe são desfavoráveis. Assim, fixo a pena-base em seu patamar mínimo, a saber: 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de multa de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, presente a circunstância agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal (Processo nº 1500166-65.2019.8.26.0624 - certidão de fls. 21/22).

Por outro lado, ressaltado o entendimento adotado outrora, adequando-me à orientação recorrente provinda das Cortes Superiores no tocante à natureza subjetiva da referida agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal, razão pela qual entendo a sua não incidência no caso em comento.

Neste sentido, confira-se:

“Em relação à agravante prevista no art. 61, I, “j”, do Código Penal, verifica-se que a sanção do paciente foi novamente exasperada em 1/6, porque os fatos foram cometidos durante a pandemia do coronavírus, estado esse de calamidade pública; Todavia, entendo que deve ser afastada a referida agravante, pois sua incidência pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática delitiva.” (STJ - AgRg no HC 677.124/SP; 5ª Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julgamento: 03.08.2021).

“Evidenciado, no caso, que o reconhecimento da agravante decorrente do estado de calamidade pública, ocasionado pela pandemia do novo coronavírus, não possui nenhum nexos com o crime praticado, inviável sua incidência, sob pena de violação à culpabilidade, em seu sentido principiológico.” (STJ - AgRg no HC 669.508/SP; 6ª Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julgamento: 15.06.2021).

De igual modo, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Veja-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Negativa do réu isolada - Depoimentos dos policiais ouvidos em juízo

firmes, coerentes e sem desmentidos - Ausência de motivos para dúvidas acerca da veracidade de suas palavras - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação pelo tráfico - Pena redimensionada - Afastamento da agravante da calamidade pública - Ausência de nexos causal - Regime prisional fechado mantido - Recurso parcialmente provido." (TJ-SP - Apelação Criminal nº 1501003-51.2020.8.26.0571; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal;

Relator(a): Desembargador(a) Jucimara Esther de Lima Bueno; Origem: Foro de Tatuí - 2ª Vara Criminal; Julgamento e Publicação: 15.02.2022).

"TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - APREENSÃO DE 47,1 GRAMAS DE COCAÍNA E 21,5 GRAMAS DE MACONHA - MERCANCIA COMPROVADA - CONDENÇÃO CORRETA, POIS LASTREADA EM PROVA FIRME DA AUTORIA E MATERIALIDADE. PENAS - AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, ALÍNEA "j" (calamidade pública) - NECESSIDADE. Não há prova de que o réu se valeu da pandemia causada pelo COVID-19 para praticar o delito - PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO." (TJ-SP - Apelação Criminal nº 1501141-18.2020.8.26.0571; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Relator(a): Desembargador(a) Willian Campos; Origem: Foro de Tatuí - 1ª Vara Criminal; Julgamento e Publicação: 01.09.2021).

Ausentes circunstâncias atenuantes, devendo a pena intermediária ser reatenuada em 1/6 (um sexto), chegando ao quantum de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de multa de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Na terceira fase, ausentes causas de aumento de pena. Da mesma forma, a ré não faz jus à redução prevista na causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, porquanto não preenche os requisitos legais, porque é reincidente em crime doloso. Destarte, torno a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de multa de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA E BENESSES LEGAIS.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por restarem não atendidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal; o regime de cumprimento fixado para o tráfico de entorpecentes e a própria natureza do delito, que é móvel de grande parte de outros crimes cometidos para a manutenção do vício, impedem a concessão da benesse por restar desatendido o inciso III do dispositivo legal retro mencionado.

Além do mais, não se olvida que a ré é reincidente, de modo que a concessão da benesse encontra óbice no inciso II, do artigo 44; bem como o montante de pena imposta aos acusados supera o limite disposto no inciso I, do citado artigo.

Pelas mesmas razões, desatendidos os requisitos do artigo 77 do Código Penal, inviabilizando a suspensão condicional da pena.

Fixo, como regime inicial de cumprimento de pena, observadas as colocações feitas por ocasião da não substituição da pena privativa, o REGIME FECHADO, único que se mostra compatível com a gravidade do delito e sua potencialidade lesiva.

Ainda quanto a fixação do regime inicial fechado, colhem-se os seguintes julgados proferidos pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"TRÁFICO DE DROGAS PEDIDO SUBSIDIÁRIO - FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO INADMISSIBILIDADE - REGIME INICIAL FECHADO ADEQUAÇÃO À ESPÉCIE DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO - INTELIGÊNCIA DA LEI Nº 11.464/2007. "Ressalto que há determinação expressa no artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, de que as penas por crime hediondo ou equiparado iniciam-se no regime fechado". RECURSO NÃO PROVIDO." (TJ-SP - Apelação Criminal nº 0057527-71.2011.8.26.0050; Órgão julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Relator(a): Desembargador(a) Marco Antonio Marques da Silva; Origem: Comarca de São Paulo; Julgamento e Publicação: 27.06.2013 e 05.07.2013) - sem destaques no original.

"No concernente ao regime prisional impositivo à espécie, também se mostra correta a fixação do inicial fechado (Lei nº 11.464/07), por duas razões principais: a uma, porque o regime fechado foi determinado de forma precisa e correta, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal e, a duas, porque o crime de tráfico de entorpecentes equiparado a hediondo, não se sujeita a regime mais brando, pois, como público e notório, provoca o reatenuamento da violência e da intranquilidade social, além da desagregação da instituição familiar" (TJ-SP - Apelação Criminal nº 990.09.042255-6; Órgão julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Relator(a):



Desembargador(a) Paulo Rossi; Origem: Comarca de Mogi das Cruzes; Julgamento e Publicação: 01.07.2009) - sem destaques no original.

"Tráfico de drogas Recurso defensivo pleiteando a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06 e a fixação do regime prisional aberto - Provas francamente incriminadoras - Condição de usuário que não elide a concomitante atividade de traficância - Crime de perigo abstrato, não se exigindo que o infrator seja flagrado no próprio ato de venda da mercadoria proibida. Pena que não comporta reparo. Réu beneficiado com a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. Regime prisional fixado com critério - Crime equiparado a hediondo, ensejando a aplicação, inicialmente, de um regime mais severo, mostrando à sociedade a eficaz repressão a esse tipo de delito - Personalidade deturpada, causadora de risco à ordem pública, de quem envereda para a prática desse tipo de criminalidade - Inaplicabilidade do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal - A competência para se discutir a respeito da detração penal é do juízo das execuções - Negado provimento." (TJ-SP - Apelação Criminal nº 0001719-19.2014.8.26.0263; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Relator(a): Desembargador(a) Fernando Simão; Origem: Comarca de Itai; Julgamento e Publicação: 10.09.2015 e 14.09.2015) - sem destaques no original.

"Tráfico de entorpecentes. Réu que, em local conhecido como ponto de venda de drogas, ao pressentir a iminência da abordagem por guardas municipais, desvencilha-se de sacola contendo 6 porções de maconha, 19 porções de cocaína e 82 pedras de crack. Localização, em seu poder e ao ensejo de revista, de R\$ 62,00 sem comprovação satisfatória de origem. Palavras dos guardas municipais coerentes e harmônicas. Versões exculpatórias dissonantes e das mais inconsistentes. Alegação de flagrante forjado repelida. Destinação mercantil das drogas bem evidenciada. Pleito de desclassificação da conduta repelido. Condenação, pelo tráfico, bem decretada. Penas que já beneficiam o acusado. Redução, com lastro no artigo 33, § 4º, não questionada pela acusação. Substituição da pena corporal por restritivas de direitos incompatível com crime equiparado a hediondo. Regime fechado necessário e decorrente, inclusive, de lei (Lei nº 11.464/07). Apelo improvido." (TJ-SP - Apelação Criminal nº 0071629-66.2012.8.26.0114; Órgão julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Relator(a): Desembargador(a) Pinheiro Franco; Origem: Comarca de Campinas; Julgamento e Publicação: 04.07.2013 e 05.07.2013) - sem destaques no original.

E também o quanto já decidido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

"O Poder Judiciário não pode ficar alheio à gravidade do problema de segurança que atormenta os moradores das cidades. E se o Juiz é, como deve ser, homem de seu tempo, atento à realidade dos fatos e ao momento que atravessa, não pode deixar de considerar a importância de suas decisões na contenção da onda de violência que se vem alastrando de maneira quase incontornável, alarmando a população e intranquilizando familiares". (In RTJ 123/547).

Soma-se a tal que é de entendimento deste juízo, em casos como este, quanto a dever ser rigorosa a repressão ao delito em tela, não havendo que se descurar, inclusive, que os supramencionados dispositivos constitucionais e legais, encontram pleno amparo na Convenção de Viena, de 1991, de Combate ao Tráfico de Drogas, promulgada no país pelo Decreto nº 154/91, especialmente aos seus artigos 4º, "a", 6º e 7º.

Atento às características do delito praticado, a quantidade de pena e regime impostos, reputo necessária a manutenção custódia cautelar para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, motivo pelo qual, NEGO-LHE o direito de recorrer em liberdade.

No sentido exposto, o magistério de Júlio Fabrini Mirabete (Código de Processo Penal Comentado, 6ª Edição, RT, p. 590), in verbis:

"O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do acusado antes e

depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional”.

E, ainda, no seguinte julgado, in verbis:

“Há lesão à ordem pública quando os fatos noticiados nos autos são de extrema gravidade, causando insegurança jurídica a manutenção da liberdade do acusado”.

(STF, HC nº 90.726, Rel. Min. Carmem Lúcia, v.u.).

Por fim, ausentes nos autos informações acerca da situação econômica dos acusados, estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na época do fato, corrigido monetariamente desde então.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal veiculada na denúncia para, decotando a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal e a causa de aumento disposta no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, CONDENAR a ré FLAIANE TAIANE VIEIRA DIAS, qualificada nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 com incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime inicial fechado, além do pagamento de multa de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal.

Conforme fundamentado acima, NEGADO O APELO EM LIBERDADE. RECOMENDE-SE A ACUSADA JUNTO AO ESTABELECIMENTO PRISIONAL EM QUE SE ENCONTRA RECOLHIDA.

Com relação à detração penal como parâmetro para estabelecimento do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, mercê do que dispõe o artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, urge proceder-se a uma interpretação sistemática da norma, atentando-se que o estabelecimento do regime inicial é pautado também pelas circunstâncias do delito (artigo 33, do Código Penal). Neste cenário, a detração constitui fator a ser considerado para fins de progressão e acompanhamento do cumprimento da pena aplicada na fase da Execução.

Autorizo a incineração da substância entorpecente, caso tal medida ainda não tenha sido providenciada.

DECLARO o perdimento do numerário apreendido com a ré, qual seja a quantia de R\$ 46,00 (auto de exibição e apreensão de fl. 16 e comprovante de depósito judicial de fls. 45/46), em favor da União, para ser revertido diretamente ao Funad, nos termos do artigo 91, inciso II, alíneas “a” e “b”, do Código Penal c.c. o artigo 63 e parágrafos, da Lei nº 11.343/06.

A ré está assistida por Defensora nomeada, circunstância apta para a presunção da não disposição de recursos para custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou do sustento de sua família. Assim, incabível se mostra a condenação ao pagamento das custas.

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários à Advogada nomeada para o patrocínio dos interesses da ré (fl. 74), nos termos do Convênio DPE/OAB.

Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente e demais comunicações necessárias.

P.I.C.

Tatui, 24 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA